

1512253-72.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... e atuaram em uma ocorrência de tráfico; que foi feito o desembarque dos dois em um local onde costumeiramente acontece tráfico; que, quando adentraram o local, viram o indivíduo se evadir, foi detido, e confessou informalmente o tráfico; que ele tinha droga em seu bolso, alguns blísteres de cocaína em pequena quantidade, confessou e em um dos locais do trajeto da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512253-72.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512253-72.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GILSON DE SOUZA FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de GILSON DE SOUZA FERREIRA, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Narra-se na denúncia: "no dia 21 de maio de 2022, por volta das 10h31, na Rua Monte Caburai, 35-A, Cidade Dutra, nesta cidade e Comarca da Capital/SP, GILSON DE SOUZA FERREIRA, qualificado a fls. 08, trazia consigo, para fins de tráfico, 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína em forma de "crack", com massa líquida total de 7,5g (sete gramas e cinco decigramas), 28 (vinte e oito) porções de fragmentos vegetais contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 16,4g (dezesesseis gramas e quatro decigramas) e 49 (quarenta e nove) porções de cocaína em pó, com massa líquida total de 61,5g (sessenta um gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência química e psíquica sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10, laudo de constatação as fls. 20/23 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado."

Promovida a notificação, foi apresentada defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial de constatação e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo, que apontam se tratar de drogas descritas nas listas F1 e F2 da Portaria n. 344/1998-SVS/MS (complemento das normas penais em branco constantes da Lei n. 11.343/06, por força do art. 66 do referido diploma legal), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Adelson relatou que não se recorda com detalhes da ocorrência; que o policial deve ser o Sgt Lopes; que ele era um dos policiais que compunham a equipe e atuaram em uma ocorrência de tráfico; que foi feito o desembarque dos dois em um local onde costumeiramente acontece tráfico; que, quando adentraram o local, viram o indivíduo se evadir, foi detido, e confessou informalmente o tráfico; que ele tinha droga em seu bolso, alguns blísteres de cocaína em pequena quantidade, confessou e em um dos locais do trajeto da fuga foi encontrado o entorpecente que ele traficava; que ele confessou que a droga era dele e destinada ao tráfico; que à época ele narrou detalhes da sua função no tráfico, inclusive horário em que estava atuando, horas em que recebeu; que viu que no ato da corrida o acusado se desvencilhou de um pacote; que ele continuou correndo, se deslocando, e metros depois ele foi detido e fizeram o caminho de volta, já com a equipe reunida, foi encontrado o entorpecente e ele confessou que estaria na prática do tráfico de drogas; que na sacola não se lembra se era cocaína ou outra coisa; que salvo engano ele tinha anotações de droga, não tem certeza; que não se lembra da quantidade de droga localizada na posse do réu; que não se lembra se tinha dinheiro com ele; que não havia ninguém na via, só ele.

A testemunha Adriano relatou que se recorda da ocorrência; que ele estava em um local conhecido do tráfico, a rua Mediterrâneo; que ele foi visto e empreendeu fuga e durante a fuga arremessou uma sacola verde com entorpecentes; que ele tinha mais porções no bolso, bem como dinheiro; que ele confirmou que estava no tráfico, então deram voz de prisão; que na sacola tinha crack, cocaína, maconha, e no bolso não lembra o que tinha, lembra que tinha porção, pouca coisa, de cocaína, não lembra a quantidade, e o dinheiro; que não se lembra se tinha anotação; que não havia ninguém próximo na via; que a sacola que apreenderam foi a que ele dispensou na fuga; que a perseguição foi rápida, não deu um minuto; que estavam com a câmera corporal e tem o registro das imagens; que ele estava sozinho, no interior da viela; que não viram ato de venda de droga; que ele confirmou que estava na venda de drogas, não sabe se ele mora ou trabalha ali perto; que só a equipe viu a prisão, não havia transeuntes; que todos os policiais usavam câmera no uniforme, todos os três.

O acusado Gilson relatou que estava trabalhando, cortando cabelo; que cortou quatro cabelos; que pegou quatro negócios, quatro drogas, na mão de dois meninos, e nisso os policiais saíram correndo, e foi de encontro com os policiais; que eles enquadraram; que estava pegando droga, é usuário, e nessa eles já abordaram,

perguntaram o nome, tudo, e devido a ter passagem eles falaram que estava vendendo, já puxaram pela roupa e acharam uns negócios que os moleques dispensaram; que eles bateram; que deram murro na costela; que começaram a filmar; que começaram a forçar; que teve que falar que era ele, sem ser ele; que já traficou quando era mais moleque; que mudou de vida depois que foi solto; que parou com essa vida; que não mora lá e foi forjado; que mencionou essas agressões antes, no fórum, na custódia; que os rapazes estavam no final da escadinha quando foi abordado; que o salão em que trabalha é na avenida 1; que pagou pela droga; que os policiais viram os menores e foram atrás; que o dinheiro que estava com ele eram R\$ 50,00 que ia usar para comprar, e obteve com seu trabalho.

Diante das provas produzidas, quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obter o que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

No caso ora em apreço, verifica-se que o depoimento dos policiais é uníssono quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão. Contradições pontuais entre os relatos a respeito de circunstâncias laterais da abordagem não são suficientes para infirmar a confiabilidade das narrativas dos policiais.

Quanto à hipótese alternativa ventilada, mostra-se de reduzida verossimilhança, tendo em vista a variedade dos entorpecentes apreendidos, a apreensão de anotações do tráfico e a quantia em espécie localizada em conjunto. A tese de que estava trabalhando não foi corroborada por nenhuma testemunha que efetivamente comprovasse o trabalho lícito alegado, seja empregador, colegas de trabalho ou mesmo clientes. Já a tese de que portava a droga para consumo próprio, mas foi agredido e forjado pelos policiais, em detrimento dos reais traficantes, é de remota probabilidade, tendo em vista que não foram constatadas lesões no exame de corpo de delito de fls. 51-52. Ademais, a equipe policial, composta por três policiais da PMSP, utilizava câmeras corporais conforme informado em audiência. A filmagem promovida por câmeras corporais policiais no sistema implementado pela PMSP, vale consignar, é contínua: vale dizer, a filmagem é iniciada assim que a câmera é retirada do dock na instituição e não há início e fim das filmagens por vontade do policial, o que afasta a hipótese de que os policiais agrediram e, depois, começaram a gravar alegada confissão forçada. Nesse contexto, a hipótese alternativa está desprovida de mínimo lastro probatório e ao que parece foi deduzida a esmo (ad hoc).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18

(dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito), o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

Quanto à tese de desclassificação, vale notar que o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de droga para uso pessoal) consiste também em tipo misto alternativo com 5 (cinco) núcleos do tipo, todos eles também constantes do art. 33, mas com a distinção de um elemento subjetivo especial: a destinação do objeto material do crime (droga) ao consumo pessoal.

Diante de tais figuras típicas similares, distintas sobretudo pela destinação da droga, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 estabelece os critérios que devem ser considerados pelo órgão julgador para estabelecer se a droga tinha destinação ao consumo pessoal: (i) a natureza e a quantidade da substância apreendida (circunstâncias objetivas), (ii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação (circunstâncias espaciais), (iii) as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (circunstâncias subjetivas).

Nesse contexto, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra probatória que dele decorre, é forçoso reconhecer que a subsunção do fato ao tipo penal mais gravoso (art. 33) depende do afastamento, para além de dúvida razoável, da destinação da droga ao uso pessoal (art. 28), mediante verificação dos critérios legais constantes do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06. Do contrário, na situação de dúvida, deve esta ser resolvida em favor do acusado, com a subsunção ao tipo penal menos gravoso, consectário dos princípios do *in dubio pro reo* e do favor rei. Nesse sentido, vale conferir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.769.822/PA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2018).

Uma vez firmadas tais premissas, no caso, a conduta não é compatível com o uso de drogas, notadamente porque as circunstâncias do fato acima destacadas, que incluem a visualização de troca de objetos/dinheiro, e a quantidade/variedade da droga, apreendida em conjunto com dinheiro em espécie, em pequenas notas, a denotar serem possível produto de vendas informais, não se coadunam com tal hipótese alternativa defensiva.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a

fim de evitar punição dúplice pelo mesmo fato (bis in idem), tal registro negativo será considerado apenas como reincidência na segunda fase, sem produzir efeito nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame. Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais de uma espécie de substância ilícita, de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Ademais, quanto à cocaína/crack, trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência, o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Quanto à quantidade de droga apreendida, não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, acresce-se à pena mínima a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por circunstância judicial negativa ("a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo" - STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). Assim, fixa-se a pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa. Na segunda fase, não incidem atenuantes e incide a agravante da reincidência (CP, art. 61. I).

Na segunda fase da dosimetria, não há limites legais mínimo e máximo de agravamento ou atenuação de pena previamente estipulados nos arts. 61 a 66 do CP. Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação da fração de 1/6 como patamar mínimo das causas de aumento/diminuição de pena constantes do Código Penal, consolidou-se a fixação da fração de 1/6 como referencial para o agravamento ou atenuação da pena em razão de cada circunstância legal, de modo que "a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). Nesse sentido, a orientação é a de que "a reincidência específica autoriza a adoção de fração maior que 1/6 na segunda fase da dosimetria" (STJ, HC 480.406/SC, Sexta Turma, DJe 25/04/2019).

Ante tais considerações, agrava-se a pena-base em 1/6 (um sexto), de modo a resultar na pena intermediária de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 729 dias-multa.

Na terceira fase, quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa. No caso, a existência de condenação penal definitiva já mencionada supra obsta a incidência da minorante.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado, com base no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP.

Em razão da reincidência e do curto interregno da prisão cautelar, não há detração

a ser promovida neste ato (CPP, art. 387, § 2º).

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado GILSON DE SOUZA FERREIRA ao cumprimento de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 729 dias-multa, em regime inicial fechado e com a multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, inclusive à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, prossiga-se na forma dos arts. 479 e 480 das NSCGJ.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade, em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Oficie-se ao Juízo da 9ª Vara Criminal Central informando o desfecho da presente e a localização do acusado, tendo em vista a citação pendente em ação penal lá em trâmite (autos n. 0004372-46.2017.8.26.0050), tal como requerido pelo Ministério Público. Serve a presente como ofício.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

São Paulo, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA